

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8595/2563

พนักงานอัยการจังหวัด
เด็กหญิง ก. โดยนาง ส. ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย อ.

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277

ป.วิ.อ. มาตรา 226/3

ผู้เสียหายเคยมาศาลแต่มีเหตุต้องเลื่อนการพิจารณา ต่อมาปรากฏตามหนังสือของสถานีตำรวจภูธร ท. แจ้งมายังโจทก์ว่าได้ส่งหมายเรียกให้ผู้เสียหายโดยมี ท. ตาของผู้เสียหายรับหมายเรียกพยานไว้แทนและ ท. แจ้งว่าบิดาของผู้เสียหายได้มารับตัวผู้เสียหายไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ทราบว่าไปพักอาศัยหรือทำงานอยู่ที่ใด ซึ่งเมื่อปรากฏตามสำเนาสูติบัตรของผู้เสียหายแนบท้ายคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าบิดาของผู้เสียหายชื่อ ด. พร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของ ด. แสดงว่าย่อมสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อหาที่อยู่ของ ด. และผู้เสียหายได้ เชื่อว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะติดตามผู้เสียหายมาเบิกความได้ จึงมิใช่กรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง (2) ส่วนบันทึกคำให้การของผู้เสียหายและบันทึกภาพและเสียงคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายซึ่งให้การต่อหน้าบุคคลในสห

วิชาชีพและในเวลาหลังเกิดเหตุไม่นาน ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อม จึงน่าจะเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (1)

สำหรับ ส. ซึ่งหลบหนีไปจากภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ และจับกุมไม่ได้ตามหมายจับ จึงเป็นกรณีมีเหตุจำเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม มีเหตุผลสมควรที่จะรับฟังบันทึกคำให้การของ ส. ในชั้นสอบสวนได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง (2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3, 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาเด็กหญิง ก. ผู้เสียหาย โดย ส. ผู้แทนโดยชอบธรรม ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

และความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมายอาญากับความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระหนงละ 12 ปี รวม 2 กระหนง เป็นจำคุก 24 ปี และให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิด (วันที่ 24 กรกฎาคม 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนแบ่งให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณา กลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ และยกคำร้องขอของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เด็กหญิง ก. ผู้เสียหาย เป็นบุตรของ ส. กับ อ. ต่อมา ส. และ อ. เลิกร้างกัน หลังจากนั้นเมื่อปี 2560 ส. อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยจนถึงช่วงเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 11 ปีเศษ และพักอาศัยอยู่ที่บ้านร่วมกับ ส. จำเลย และน้องสาวของผู้เสียหายอีก 2 คน อายุ 4 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ผู้เสียหายจึงเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับจำเลย ลักษณะการพักอาศัยของครอบครัวนั้น จำเลย ส. และน้องสาวของผู้เสียหายอีก 2 คน จะนอนรวมอยู่ในมุ้งเดียวกัน ส่วนผู้เสียหายจะแยกนอนเพียงลำพัง แต่ไม่มีการกั้นห้อง มีเพียงลังพลาสติกใส่เสื้อผ้าวางกั้นเป็นส่วนสัดส่วนเท่านั้น วันที่ 28 กันยายน 2560 ส. แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานกระทำชำเราผู้เสียหาย ชั้นสอบสวนพนักงาน

สอบสวนส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย ผลการตรวจพบรอยแผลฉีกขาด
เก่าที่ช่องคลอดของผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิด
ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีและฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความว่าจำเลยเป็น
คนร้ายที่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง โจทก์คงมีเพียงบันทึกคำให้การของผู้เสียหาย
และบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเพียง
พยานบอกเล่ามาแสดง โดยเมื่อโจทก์ไม่สามารถนำตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์
พยานมาเบิกความต่อศาลต่อหน้าจำเลย จำเลยย่อมไม่มีโอกาสถามค้านเพื่อให้ข้อเท็จ
จริงเป็นที่กระจ่างแก่ศาลได้ นอกจากปรากฏว่าผู้เสียหายเคยมาศาลแต่มีเหตุต้อง
เลื่อนการพิจารณา ต่อมาปรากฏตามหนังสือของสถานีตำรวจภูธรแจ้งมายังโจทก์ว่า
ได้ส่งหมายเรียกให้แก่ผู้เสียหายโดยมีนาย ท. ตาของผู้เสียหายรับหมายเรียกพยาน
ไว้แทน และนาย ท. แจ้งว่าบิดาของผู้เสียหายได้มารับตัวผู้เสียหายไปอยู่ด้วยที่
กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ทราบว่าไปพักอาศัยหรือทำงานอยู่ที่ใด ซึ่งเมื่อปรากฏตาม
สำเนาสูติบัตรของผู้เสียหายว่าบิดาของผู้เสียหายชื่อ อ. พร้อมระบุหมายเลขประจำ
ตัวประชาชนของ อ. แสดงว่าย่อมสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อหาที่
อยู่ของ อ. และผู้เสียหายได้ เชื่อว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะติดตามผู้เสียหายมาเบิกความได้
จึงมิใช่กรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถ นำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน
หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็น
พยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอก
เล่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง (2)
แต่บันทึกคำให้การของผู้เสียหาย และบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงคำให้การชั้น
สอบสวนของผู้เสียหาย ซึ่งให้การต่อหน้าบุคคลในสหวิชาชีพและในเวลาหลังเกิดเหตุ

ไม่นาน ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อม จึงน่าจะเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (1)

ส่วน ส. ซึ่งหลบหนีไปจากภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ และจับกุมไม่ได้ตามหมายจับ จึงเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมีเหตุผลสมควรที่จะรับฟังบันทึกคำให้การของ ส. ในชั้นสอบสวนได้ตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (2) อย่างไรก็ตามปรากฏว่า เดิม ส. มารดาของผู้เสียหายและผู้เสียหายให้การต่อพนักงานสอบสวนในทำนองเดียวกันว่าผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศโดยไม่ได้อ้างการว่าเกิดการกระทำอย่างไรขึ้น ซึ่งการกระทำชำเราไม่อาจจะใช้สิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายก็ตาม ผู้เสียหายน่าจะทราบได้ ยิ่งทำให้เห็นว่ามี ความจำเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยมาสืบเพื่อให้รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริง แม้โจทก์จะมีนาง น. มาเป็นพยานเบิกความว่าผู้เสียหายว่าถูกจำเลยข่มขืน 1 ครั้ง และมีร้อยตำรวจเอก ส. พนักงานสอบสวนมาเบิกความว่า ได้สอบคำให้การ ส. และผู้เสียหายไว้ แต่พยานทั้งสองก็เป็นเพียงพยานบอกเล่า นอกจากนี้แม้ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์จะระบุว่ามียารอยฉีกขาดเก่าที่ช่องคลอดของผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ได้แน่นอนว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายจริง เมื่อโจทก์ไม่สามารถนำผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความต่อศาล โดยที่จำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด พยานหลักฐานของโจทก์ย่อมไม่พอให้รับฟังลงโทษจำเลยได้ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า สมควรรับฟังวัตถุพยานที่เป็นบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายเสมือนหนึ่งคำเบิกความของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคท้าย ด้วยนั้น โจทก์ไม่ได้ฎีกาโต้เถียงว่ามีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคท้าย อย่างไร จึงไม่จำต้องวินิจฉัย ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องและทำละเมิดผู้ร้อง จึงไม่จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่

ผู้ร้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณายกฟ้องและยกคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชัยพัฒน์ ชินวงศ์-วีรวิทย์ สายสมบัติ-กษิตศ มงคลศิริภัทรา)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายอัฐฐา วิลัยทิพย์
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายวิชัย วิริยะสุนทรวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>